

1501102-85.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501102-85.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501102-85.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2208565/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 19390163 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

2296/21/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2208565 - DEL.POL.BIRIGUI, 2296/21/309 -

DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR MANUEL DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1501102-85.2021.8.26.0603 (Controle 1608/2021)

VISTOS.

VITOR MANUEL DOS SANTOS, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 11h43min, no imóvel localizado à Rua Alzira Bersani Freitas, nº 170, Bairro Portal da Pérola, cidade e comarca de Birigui, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 08 (oito) porções de cocaína, pesando um total de 811,54 gramas; 11 (onze) tijolos de maconha, pesando 8.722,11 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 1.200,26 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de fls. 35/37, 38/40, 121/123 e 124/126.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 157), cuja peça foi juntada às fls. 146/147, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 09 de dezembro de 2021 (fls. 172/173).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas em comum, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 200/201).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 205/214).

Já a defesa do acusado requereu a absolvição, alegando ilicitude da busca realizada pelos policiais na residência do acusado. Subsidiariamente, pediu que seja aplicada a pena no mínimo legal ou, em caso de aumento nesta fase, que este não extrapole a fração de 1/6; reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade penal relativa; aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; fixação do regime aberto; convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 306/311).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A matéria arguida pela defesa, quanto à busca domiciliar na casa do acusado sem mandado judicial, fica rejeitada.

Pelo que se relatou na denúncia, os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pela Avenida Afif José Abdo, viram VÍTOR na companhia de João Lucas Oliveira da Silva, os quais demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura policial. Na abordagem, localizaram entorpecente com o acusado, o qual admitiu que havia mais drogas em sua residência, onde localizaram 811,54g de cocaína e 8722,11g mais 1200,26g de maconha.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo

Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar:

“De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formado disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Em função disso, sempre que houver fundada suspeita da ocorrência do referido ilícito penal, não será possível falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio ou específico, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Afirmar-se o contrário implicaria prestigiar a atividade criminosa, em detrimento do trabalho policial realizado por agentes públicos regularmente investidos em suas funções, que ficariam inviabilizadas, com prejuízo irreparável para a sociedade. Imagine-se, por exemplo, que policiais estivessem realizando ronda rotineira, no exercício do policiamento preventivo e, ao passarem diante de uma residência qualquer, ouvissem gritos de socorro de uma mulher. A prevalecer o raciocínio segundo o qual o ingresso em residência só pode ocorrer quando houver segura conclusão acerca de crime em seu interior, mesmo diante da suspeitada ocorrência de violência doméstica, os agentes públicos estariam impossibilitados de intervir, e só poderiam ingressar na residência após a obtenção de ordem judicial, ou se a tanto autorizados pelo possível agressor, ou seja, quando o socorro à vítima já não seria mais útil. Tão absurda situação equivaleria à concessão de um passe livre para que residências servissem de palco para a prática dos mais diversos e graves delitos (homicídios, sequestros, lesões corporais, tráfico, estupros de vulneráveis, etc.), colocando a proteção às vítimas e da sociedade em patamar inferior aos direitos dos criminosos, e privilegiando a impunidade)... E nem se diga, por outro lado, que a diligência policial não foi devidamente documentada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se exigia documentação e registro audiovisual para o ingresso de policiais em residências (Habeas Corpus nº 598051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP, de que foi relator o Ministro Alexandre de Moraes, realizado no dia 02 de dezembro de 2021, ficando assentado que é “Incabível, portanto, na presente hipótese, em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias, para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”. Enfim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem é o caso de se determinar o desentranhamento de qualquer elemento probatório dos autos, já que todas as provas produzidas se afiguram válidas. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439, Comarca de Pereira Barreto, 11ª Câmara de Direito Criminal, V.U., j. 03/02/22, rel. Des. XAVIER DE SOUZA).

Afastada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o recibo de entrega de preso (fls. 03/04); a nota de culpa (fl. 08); o boletim de ocorrência (fls. 20/26); o auto de apreensão e exibição (fls. 15/16); os autos de constatação prévia (fls. 36/40); os laudos periciais (fls. 121/126); o relatório policial (fls. 128/130); os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pelo acusado, em ambas as fases da persecução penal.

O acusado, na delegacia e em juízo, confessou que estava na posse das drogas em sua residência e que apenas guardava para um traficante em troco de R\$500,00. Afirmou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência (fls. 07 e 200/201). A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão da réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, os policiais militares Duilio Alessandro Longhi Baliero e Rafael Gonçalves Araujo, ouvidos em ambas as fases, relataram que, após abordagem, o localizaram droga com o acusado, o qual informou que tinha mais drogas em sua residência e indicou os locais onde estariam parte das drogas, sendo que uma parte estaria dentro de uma caixa térmica, no quintal da residência, e a outra parte estaria em uma mochila, dentro da gaveta de um rack, também no quintal, em uma varanda e autorizou a entrada. Encontraram, na mencionada caixa térmica, 11 tijolos de maconha, envoltos em um plástico preto, bem como localizaram, na mochila localizada no rack, um par de coronha de madeira de revólver, uma munição de calibre .38 percutida mas não deflagrada (picotada), dois rolos de plástico filme, duas facas com resquícios de maconha, duas balanças de precisão (uma grande e outra pequena), 5 pacotes com embalagens plásticas e 19 porções de “maconha” em tamanhos variados, envoltos em plástico filme, preparadas para a venda. Posteriormente, foi realizada busca no quarto de Vitor, sendo localizado, neste local, R\$ 62,00 reais em espécie, 4 porções de “maconha”, 8 porções em sacos plásticos de “cocaína” em pedras, um tijolo parcial de pasta base de “cocaína” e um celular da marca Motorola (fls. 03/04, 05 e 200/201).

Os policiais confirmaram a apreensão dos entorpecentes na residência do acusado.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse das testemunhas em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ela a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Por fim, a testemunha Maria Aparecida dos Santos, mãe do acusado, ouvida nas duas fases, disse que chegou em sua casa e avistou o acusado trancado dentro da viatura. Perguntou aos policiais se eles tinham ordem judicial para entrar, sendo que os policiais lhe disseram que “eles que mandavam”. Não viu os policiais encontrando as drogas em sua residência, apenas viu quando os entorpecentes estavam todos colocados em uma área no quintal. Não tem conhecimento de que seu filho possuía entorpecentes na residência (fls. 06 e 200/201).

As substâncias apreendidas consistem realmente em “maconha” e “cocaína” (exames químicos-toxicológicos de fls. 121/126).

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que os agentes tragam consigo, guardem ou tenham em depósito as drogas, para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado porque trazia consigo, guardava e tinha em depósito as drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Anoto que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto

alternativo, possuindo vários núcleos. Logo, quanto à caracterização do tráfico de drogas, pouco importa o fato de ter o réu estar guardando para terceiros, porque o artigo 33, caput, da Lei de Drogas, incrimina, dentre várias, as condutas de guardar e ter em depósito a droga para fins de comércio a terceiros, ainda que o entorpecente seja de terceira pessoa.

De outra parte, a diversidade e a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína); as circunstâncias da abordagem (próprio réu informou o local em que estavam as drogas em sua residência), a forma de acondicionamento das drogas (tijolos e porções embaladas, prontas para o comércio), a apreensão de dinheiro, balanças, plástico filme, faca, saco, caixa térmica e celulares, bem como a confissão do réu em ambas as fases, estão a caracterizar a traficância.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito 08 (oito) porções de cocaína, pesando um total de 811,54 gramas; 11 (onze) tijolos de maconha, pesando 8.722,11 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 1.200,26 gramas, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de consumo de terceiros.

A conduta da ré encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta Maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução de considerável quantidade de droga no mercado, se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-los com a sanção base mínima, tratando-os igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes. Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de

substância tóxica apreendida" (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro - JUTACRIM 44/293).

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o "modus operandi" do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível "reformatio in pejus", a pena cominada na r. sentença deve prevalecer - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 23.8.2007 - V.U. - Voto n. 6.277).

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa (réu menor de 21 anos na época dos fatos) e reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

Ainda nesta fase, não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de droga (nada menos do que 9.922,37 gramas de maconha e 811,54 gramas de cocaína), que o acusado se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, guardando grande quantidade de droga na residência apontada na denúncia, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, tanto que assumiu fazer parte da chamada "cadeia do tráfico", sendo ele a pessoa encarregada de guardar a droga em sua casa, a mando de outro traficante.

Neste sentido, já se decidiu:

" Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa."

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº

8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR VITOR MANUEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 03/08/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 50394-60, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

O fato de o caso ser enquadrado pela jurisprudência no chamado "tráfico privilegiado" não autoriza, automaticamente, a substituição da pena corporal por restritivas de direito, em razão de sua gravidade.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em

sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no

artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastasse todos os argumentos expostos no voto supracitado, no caso concreto, a substituição não é possível, porque a pena ultrapassou quatro anos e o crime é considerado grave e demonstra periculosidade considerável do réu, que praticava o tráfico mantendo em depósito grande quantidade de entorpecentes, o que merece maior reprovação do Poder Judiciário.

O acusada deverá continuar a responder presa a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida à fls. 66/72, bem como aqueles expostos na decisão de fls. 158/159 que indeferiu pedido de liberdade provisória.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada (fl. 71), nada havendo a ser decidido. Como o acusado não fez prova da procedência lícita do dinheiro apreendido (R\$ 88,00) às fls. 15/16, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes por eles praticados, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06 decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos objetos apreendidos (cabo de madeira taurus, faca, duas balanças, película/filme, saco e caixa térmica), apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Por fim, quanto aos celulares apreendidos às fls. 15/16, apesar de ser instrumento do crime de tráfico, diante de sua natureza, não é caso de perda em favor do SENAD, mas sim destruição, a qual fica, desde já, determinada, mas que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado da presente, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 88,00) e sobre a destruição dos objetos apreendidos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos

do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA